

1501129-33.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... da filha de Douglas no crime de tráfico, não bastando para o seu reconhecimento a simples menção ao fato de que os autores do crime sempre estariam na companhia de criança, "talvez para passar despercebidos da ação policial" (fls. 7). Tal dispositivo prevê a qualificadora quando a prática do tráfico "envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501129-33.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2228440/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26902957 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENCA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II,

"j" do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD e Art. 12 "caput" da Lei 10.826/03 c/c

Art. 69 "caput" do CP

Data da Audiência:

03/10/2022

Aos 03 de outubro de 2022, às 14 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; os Réus DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENCA e LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA, acompanhados do Defensor, Dr. Rudnei Souza; bem como as testemunhas arroladas Julio Gonçalves Machado Queiroz (GCM) e Fernando Neves dos Santos (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a

gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, os réus foram entrevistados de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENÇA e LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", e art. 35, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de agosto de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENÇA e LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA, ambos qualificados nestes autos, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Ainda, em 21 de agosto de 2022, por volta das 16h35, na rua Cícero Cornélio Pereira e na rua Saladino Simões de Almeida, nº 280, Rosa Garcia I, nesta cidade e Comarca de Tatuí, DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENÇA e LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportavam, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 03 "tijolos" de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 414 gramas e 03 porções a granel de cocaína, com peso bruto aproximado de 280 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por fim, em 21 de agosto de 2022, por volta das 16h35, na rua Saladino Simões de Almeida, nº 280, Rosa Garcia I, nesta cidade e Comarca de Tatuí, DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENÇA e LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior da residência, 03 munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que os denunciados - que são irmãos - praticavam o tráfico, dividindo as tarefas na empreitada criminoso. Para tanto, DIEGO e LUCAS utilizavam o automóvel marca "WV", modelo "Gol Special", placas DFW 3180/Boituva/SP, para o transporte dos entorpecentes e mantinham o restante da droga na casa, onde também promoviam o fracionamento e o embalo das porções. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo "Gol" transitando pela via pública. O motorista, LUCAS, ao notar aproximação da viatura, freou bruscamente, engatou a marcha ré e, manobrando rapidamente, fugiu. Houve breve acompanhamento, até que foi possível a abordagem. LUCAS e o passageiro DIEGO desembarcaram, deixando no veículo uma criança de 07 anos de idade. Dentro do automóvel, no banco do passageiro, foi localizada a sacola plástica contendo 03 porções grandes de cocaína. Os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Inquirido, DIEGO admitiu que havia mais drogas na residência, bem como dinheiro proveniente do comércio espúrio. No imóvel, sobre o guarda-roupas, foram encontrados 03 "tijolos de maconha", dezenas de embalagens plásticas utilizadas para o embalo de porções individuais e R\$2.150,00. Em seguida, dentro de uma bolsa, foram localizadas 03 munições. Foram apreendidos, ainda, aparelhos de telefonia celular e balança de precisão. Auto de prisão em flagrante às fls. 6 e 25, convertida em prisão preventiva às fls. 49/51. Auto de exibição e apreensão às fls. 13/4. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 11. Certidão de nascimento do menor J. P. R. P. às fls. 178. Laudo pericial de exame definitivo em entorpecente às fls. 211/5. Laudo pericial de exame em munição de arma de fogo às fls. 216/9. Notificação de Diego às fls. 221. Notificação de Lucas às fls. 222. Defesa preliminar apresentada às fls. 174/5, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi

recebida em 20/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 224/5). Citação de Diego às fls. 248. Citação de Lucas às fls. 246. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, conforme já registrei às fls. 173, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ainda, preliminarmente, mormente diante da cogitação da combativa defesa técnica a respeito do abuso de autoridade (fls. 175 e 200), bem como das ponderações lançadas em sede de alegações finais a respeito da ausência de atribuição da guarda municipal, não observo qualquer irregularidade na perseguição de trânsito, bem como no ingresso dos guardas municipais na casa de Diego. De antemão, em se tratando de uma operação de trânsito, os agentes tinham legitimidade para sair no encalço do veículo que tentou se furtar à fiscalização, sendo que o casual encontro de drogas no interior dele autorizou as providências sucessivas. Valor constitucional a ser respeitado é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, não sendo possível que alguém imagine que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de mais de quatrocentos gramas líquidos de maconha naquele local, afora a cocaína apreendida na via pública, os servidores tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial, francamente. Não há dúvida de que a instituição guarda municipal não é naturalmente vocacionada a esse tipo de diligência, todavia, o ingresso na residência restou mais do que legitimado, imprescindível, senão exigido naquelas circunstâncias. Ademais, admitiu o interrogado que fez verdadeiro "pedido" para que os guardas apanhassem a droga na residência, afinal, em perdendo o entorpecente para a "polícia", não teria dívida com o fornecedor. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas. Pois bem, de antemão, importa consignar que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das

quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-

80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018).

Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação, embora se trate de irmãos custodiando substancial quantidade de variadas drogas. Note-se que não se trouxe qualquer informação pretérita concreta a respeito do envolvimento dos acusados de maneira conjugada, por isso não se afastando a hipótese de que a comunhão de propósitos fosse recente ou sequer existente até então. Reforçando: os guardas ouvidos sob contraditório deixaram de trazer informações sobre a atuação conjunta dos Réus, afora aquela verificada nestes autos, pois, sequer conheciam os abordados. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre eles, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico, embora casual a abordagem aqui versada. Nesse particular, verifiquemos a prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Os guardas municipais Júlio e Fernando narraram (faz-se, aqui, uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam, sem contradições) que faziam fiscalização de trânsito quando perceberam que um veículo freou bruscamente, engatou a ré, passou irregularmente por um trecho de área verde e seguiu então acompanhado, com sinais ostensivos da viatura, por uns oitocentos metros, até parar no estacionamento de um

supermercado, onde verificado que também traziam uma criança e, no banco do passageiro, até então ocupado por Diego, naquele automotor conduzido por Lucas, logo visualizadas, porque aparentes, três porções de cocaína a granel. Prosseguiram os agentes detalhando que diante de um irmão silente, Diego assumiu a responsabilidade pela droga e acresceu que na sua casa havia mais entorpecente, o qual queria fosse retirado pelos próprios, evitando-se maiores perdas. Então, para lá os depoentes estenderam as diligências, ali apreendendo balança, cerca de um milheiro de eppendorfs, 3 tijolos de maconha, R\$2150,00 e três munições 9mm, essas que Diego disse desconhecer. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das drogas veio atestada pelo laudo de fls. 211/5, como sendo: 3 porções de maconha, com 431,63 gramas líquidos e 3 porções de cocaína, com 289,35 gramas líquidos. De outro turno, o laudo de fls. 216/9 apontou que um dos cartuchos era eficaz. Interrogados, doravante superando os sintomáticos silêncios de outrora, fls. 21/2, Lucas disse ter sido chamado enquanto trabalhando para dar uma carona para o irmão, cujo manuseio de drogas desconhecia, o que Diego ratificou, admitindo que guardava as drogas a mando de terceiro, para quem, ao lado do filho, buscara a cocaína naquele momento. Pois bem, para além da parcial confissão de Diego, já prescindível para a definição meritória em desfavor de todos, desacreditada a versão de Lucas, isso porque, pese casual a sua abordagem e ainda que nada trouxesse consigo ou na residência (restou estabelecido nas qualificações de fls. 21/2 e oitiva do GCM Júlio que os acusados não moravam juntos e as drogas estavam tanto no veículo quanto na casa de Diego), fato é que ele, na condição de motorista, na condução de um veículo cuja origem não demonstrou, afinal, desordenadamente, em depoimento bastante confuso (o que não se coaduna com a situação daquele que deve trazer elementos sérios para desmerecer conclusão que emerge daqueles amealhados nos autos – a propósito, o silêncio no interrogatório, já a partir de solo investigativo, é sem dúvida direito constitucional, todavia, há que se ter em conta que em hipóteses que tais, declarar os fatos é imprescindível à defesa do interrogado) alegou que havia adquirido há dois dias, e levando o irmão com expressiva quantidade de cocaína, trazida de forma aparente, tentou fugir da abordagem da guarda municipal, isso justificando na falta de habilitação (embora salientando que sempre foi liberado dessas abordagens, porque notoriamente trabalhador). Enfim, inarredável que tinha conhecimento do que era trazido pelo corréu, tendo participado da empreitada criminosa, ainda que não responsável pelos demais entorpecentes encontrados na residência do irmão. Quanto à finalidade mercantil, escancarada diante da variedade e quantidade, com a nota de que sequer se intitulam usuários os interrogados. Veículo, celulares, numerário e demais itens apreendidos, naturalmente vinculados ao contexto de tráfico elucidado, devem ter as suas perdas decretadas, óbvio, ressaltado que a despeito de alegar, Diego não demonstrou que parte do numerário provinha de uma pensão do filho órfão de mãe e, de toda forma, a confusão nessa hipótese é bastante evidente e não pode favorecer o denunciado. Derradeiro, na verdade, o filho de Diego foi utilizado como escudo, na tentativa de despistar uma ação policial, e isso é evidente. Quanto ao fato de o crime envolver essa criança, conforme certidão de nascimento às fls. 178, não há dúvidas de que, no momento da ação criminosa, os agentes traziam consigo o menor, o que poderia, realmente, sugerir o envolvimento dele no delito, notadamente como tática, para despistar a ação de policiais, já se frisou, assim atraindo a incidência do dispositivo mencionado na prefacial, art. 40, VI, da Lei de Drogas, mesmo porque o texto não especifica a maneira pela qual deve se dar esse envolvimento. Conquanto assim já tenha decidido em caso em trâmite perante esta Vara, no qual havia, inclusive, denúncia anônima dando conta de que dois homens traficando a bordo de um veículo, rotineiramente o faziam na companhia da filha de um deles (refiro-me à sentença proferida nos autos do processo 1500802-93.2019.8.26.0571), fato é que o decreto condenatório,

nesse particular, foi reformado pela Superior Instância, por v. Acórdão relatado pelo Desembargador Carlos Bueno (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, d.J. 30/01/2020), de cujo corpo se extrai a seguinte cátedra: "[....] Mas deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pois não se verifica nos autos a comprovação de envolvimento da filha de Douglas no crime de

tráfico, não bastando para o seu reconhecimento a simples menção ao fato de que os autores do crime sempre estariam na companhia de criança, "talvez para passar despercebidos da ação policial" (fls. 7). Tal dispositivo prevê a qualificadora quando a prática do tráfico "envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação". No caso, a filha de Douglas tem apenas um ano e meio, não se podendo concluir que, apenas por estar no veículo, estaria sendo envolvida no crime pelos recorrentes. Trata-se de mera suposição, insuficiente para o reconhecimento da qualificadora.[...]. Orientado por essa diretriz, e principalmente porque no presente caso sequer notícias anteriores havia a respeito do envolvimento desse menor, ou até mesmo da associação entre os réus, na verdade, os guardas sequer os conheciam, lembre-se, descabida a aplicação da causa de aumento, sem prejuízo de que a circunstância mereça consideração na primeira fase da dosimetria da pena. Lado outro, já se disse que impossível imputar ao condutor do veículo a responsabilidade pelos itens encontrados na casa do irmão, aí incluídas as munições e tendo em conta que ao menos uma delas estava apta para utilização, Diego deve ser responsabilizado por esse crime que é de perigo abstrato, independente da apreensão concomitante de armamento, como sustenta a combativa defesa. Aliás, num cenário de traficância de relevo, tal qual aquela aqui elucidada, bem se imagina a finalidade e conveniência da custódia de armas ou munições. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia em relação aos dois acusados, com a nota de que restarão absolvidos da acusação de associação e Lucas também da infração ao disposto no artigo 12 da Lei de Armas, ilícito atribuído apenas ao irmão corréu, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu Lucas. Na primeira fase, a quantidade de entorpecente apreendida é significativa, ainda que se possa atribuir a ele apenas a participação no tráfico de cocaína, afinal, eram 289,35 gramas líquidos dessa danosa substância, cujo grama, pela observação do que ordinariamente acontece, pode-se dizer pela experiência de atuação nesta Vara criminal, gira em torno de R\$30,00, ou seja, expressão monetária de mais de oito mil e seiscentos reais, afóra a circunstância de que o tráfico era realizado mediante a utilização de veículo, e por aí se vê a desenvoltura da traficância, consignado que Réus são condenados por tráfico, vez por outra, por trazer algo em torno de dez unidades de 0,16 gramas líquidos dessa droga. Também não se pode olvidar que o Réu praticava a traficância em concurso de agentes, transportando em veículo próprio e nele trazendo uma criança, seu sobrinho (certidão de nascimento às fls. 178), o que acentua sobremaneira o desvalor da conduta. Por essas razões, tenho que, a despeito da primariedade, a pena-base deve ser elevada em 1/5, então fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela elevo em 1/6 a pena, atingindo 07 anos de privação de liberdade e 700 dias-multa. Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente foi apanhado num cenário de desempenho profissionalizado do tráfico, na posse de quase trezentos gramas líquidos de cocaína, estoque já se disse, mensurado a preço de varejo, em mais oito mil e seiscentos reais, trazido em veículo próprio, a indicar fizesse disso o seu meio de

vida, ainda que em concomitância com eventuais atividades lícitas, as quais somente alegou mas não demonstrou. E não é, por certo, o neófito na traficância que tem consigo, mesmo que por confiança de alguém maior nesse organograma, e que não quer identificar, essa considerável quantidade de droga à disposição, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade da substância. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Em hipótese bem menos grave, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções, ainda que tudo de droga mais danosa, crack, decidi nesta Vara, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte câtedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal o Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Assim, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, pois se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao julgador a fixação do regime adequado à repressão da conduta, ressocialização do indivíduo e proteção do corpo social. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, para além do profissionalismo aqui demonstrado e do montante de pena superior a oito anos de privação de liberdade, o que por si só está a exigir tal estabelecimento, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]" Não olvido a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP, Relator Min. Rogério Schietti, a recomendar a fixação do regime semiaberto nessa hipótese, todavia, o vulto da traficância elucidada está a desautorizar tal solução. Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. B) Quanto ao Réu Diego. Crime

do art. 33. Na primeira

fase, a quantidade de entorpecente apreendida é significativa, afinal eram 289,35 gramas líquidos de cocaína, cujo grama, pela observação do que ordinariamente acontece, pode-se dizer pela experiência de atuação nesta Vara criminal, gira em torno de R\$30,00, ou seja, expressão monetária de mais de oito mil e seiscentos reais dessa droga, afora 431,66 gramas líquidos de maconha, cujo grama, também pode-se dizer segundo o mesmo conhecimento, gira em torno de R\$ 5,00, ou seja, um pouco mais de dois mil e cem reais em estoque de maconha e R\$ 2.150,00 em pecúnia, num total atribuível a esse sentenciado superior a doze mil reais. A isso se acresce a circunstância de que o tráfico era realizado mediante a utilização de veículo, e por aí se confirma a desenvoltura da traficância, consignado que Réus são condenados por tráfico, vez por outra, por trazer algo em torno de dez unidades de 0,16 gramas líquidos dessa droga. Também não se pode olvidar que o Réu praticava a traficância em concurso de agentes, e nele trazendo uma criança, seu próprio filho (certidão de nascimento às fls. 178), o que acentua sobremaneira o desvalor da conduta. Por essas razões, tenho que, a despeito da primariedade, a pena-base de Diego deve ser elevada em 1/3, atingindo 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda, em prestígio, inclusive, ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", CP uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), todavia, fica ela compatibilizada com a atenuante da confissão, então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente foi apanhado num cenário de desempenho profissionalizado do tráfico, na posse de mais de setecentos gramas líquidos entre cocaína e maconha, além de numerário, expressão financeira, já se disse, superior a doze mil reais, utilizando veículo na empreitada, a indicar fizesse disso o seu meio de vida, ainda que em concomitância com eventuais atividades lícitas, as quais somente alegou mas não demonstrou. E não é, por certo, o neófito na traficância que tem consigo, mesmo que por confiança de alguém maior nesse organograma, e que não quer identificar, essa considerável quantidade de droga à disposição, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade da substância. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Em hipótese bem menos grave, de 12,31 gramas, distribuídos em 40 porções, ainda que tudo de droga mais danosa, crack, decidi nesta Vara, em condenação que acabou confirmada pela Superior Instância, com a seguinte cátedra, naquilo que interessa: "[...] Ausentes agravantes, na derradeira, a despeito da primariedade, não era mesmo o caso de

aplicação do redutor da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, diante das peculiaridades, porque foi preso guardando e mantendo em depósito 40 "porções" de crack (12,310 g), destacando-se, ainda, a apreensão do dinheiro - sem origem comprovada - e a falta de demonstração de que exerceria qualquer labor lícito, indubitáveis indicadores de dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. [...]" (Apelação nº 0000232-89.2016.8.26.0571, Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, d.J. 19/04/2017). Assim, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. B) Quanto ao Réu Diego. Crime do art. 12 da Lei de Armas. Na primeira fase, gravidade ínsita, pena-base no mínimo legal, 01 ano de detenção e 10 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do acusado. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), elevo em 1/6 a pena, atingindo 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa, anotado que aqui não houve confissão, já que Diego nega conhecimento a respeito da existência das munições entre os demais materiais ilícitos. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento para a pena do tráfico será o inicial fechado, pois se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao julgador a fixação do regime adequado à repressão da conduta, ressocialização do indivíduo e proteção do corpo social. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, para além do profissionalismo aqui demonstrado e do montante de pena superior a oito anos de privação de liberdade, o que por si só está a exigir tal estabelecimento, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Não olvido a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP, Relator Min. Rogério Schietti, a recomendar a fixação do regime semiaberto nessa hipótese, todavia, o vulto da traficância elucidada está a desautorizar tal solução. Sem dúvida, em se tratando de cenário gravoso, o regime para o cumprimento da concomitante pena da Lei de Armas deve ser também o mais gravoso para a hipótese, no caso, o semiaberto. Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, ABSOLVIDOS ambos os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, e ABSOLVIDO o RÉU

LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA da acusação de infração ao disposto no art. 12 da Lei 10.826/2003, isso tudo com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENA-LO, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR o Réu DIEGO ELIAS DE MIRANDA PROENÇA, por incurso no art. 33, caput, da

Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e por incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Fica decretada, igualmente, a perda do veículo apreendido às fls. 13/4, qual seja, o VW/GOL SPECIAL placa DFW3180, chassi 9BWCA05Y63T196284, ano/modelo 2003/2003, pois utilizado para as atividades de traficância, devendo aquele que consta como proprietário perante o Detran, qual seja, Edilene da Silva Rodrigues de Oliveira, ser cientificado do teor desta decisão. A propósito, evidente que o acusado LUCAS ARIEL DE MIRANDA PROENÇA se utilizou de automóvel sob seu poder para a prática do tráfico, nos termos do art. 92, III, do CP, fica decretada a inabilitação para dirigir veículos, oportunamente oficiando-se ao DETRAN. Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciais condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado, por incidência em traficância com expressão monetária considerável, em concurso de agentes, mediante utilização de veículo, no qual alocada uma criança, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Ademais, a questão da custódia provisória passou recentemente incólume sob o crivo da Superior Instância nos autos do HC cujo v. Acórdão encontra-se digitalizado às fls. 251/6, não se justificando agora, no momento da afirmação da culpa em sede de cognição exauriente, seja desautorizada a solução referendada pelo órgão de revisão. Recomende-se-os, portanto, no presídio em que se encontram recolhidos. Expeçam-se imediatamente guias de recolhimento provisórias. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, ficam recebidos os seus recursos, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA